

1506822-34.2021.8.26.0344

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... no sentido de que "[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 3. Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506822-34.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506822-34.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROGER APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de ROGER APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça de acusação que no dia 27 de julho de 2021, por volta de 17:10 h, na Rua dos Cravos nº 106, nesta cidade de Marília, ROGER APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado às fls. 04, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 4,62g (quatro gramas e seiscentos e vinte miligramas) de cocaína, na forma de 'crack', distribuídas em 43 (quarenta e três) porções, conforme auto de apreensão exibição de fls. 09, laudo pericial de constatação de fls. 15/17 e laudo químico-toxicológico de fls. 61/65. Segundo o apurado, na data dos fatos, ROGER APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA praticava o tráfico de drogas no sobredito local, o que foi noticiado à Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes - DISE desta Comarca, em informação que dava conta de comércio de drogas na Rua dos Cravos, cujo traficante vestia uma camiseta de cores amarelo e vermelho e bermuda azul.

No local indicado, policiais civis passaram a observar e identificaram o denunciado com as vestimentas anunciadas, bem como o momento em que ele efetuou uma venda para dois indivíduos que foram ao seu encontro.

Os agentes avistaram que, após breve diálogo, ROGER se dirigiu a um barraco nas imediações, retornou com entorpecentes e os entregou aos usuários.

Com o apoio de outros policiais que estavam nas imediações, fizeram a abordagem do

denunciado e, em poder dele, localizaram R\$ 29,00 (vinte e nove reais) em dinheiro. Em buscas no citado barraco, com auxílio do canil da Polícia Militar, foram localizados em um buraco na parede da cozinha, 43 (quarenta e três porções) de cocaína, embaladas em plástico transparente.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04.

Boletim de ocorrência às fls. 09/11.

Auto de apreensão exibição às fls. 12.

Fotografias às fls. 13/16.

Laudo pericial de constatação às fls. 18/20.

Laudo químico-toxicológico de fls. 64/67.

Relatório final elaborado pela autoridade policial às fls. 69/73.

Devidamente notificado, o réu apresentou Defesa Prévia às fls. 103/105.

A denúncia foi recebida em 03 de fevereiro de 2022 (fls. 111/112).

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 24/02/2022 foram colhidos os depoimentos das testemunhas Wellington Corredato da Silva e Fabio Portaluppi Marinho, bem como o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, eis que devidamente comprovada a materialidade e a autoria delitivas. No tocante à dosimetria da pena, requereu, na primeira fase, a fixação da pena base acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Na segunda e na terceira fases não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Possível a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A douta Defesa, por sua, requereu, em memoriais orais, em sede de preliminar, o reconhecimento da ilicitude da prova, com sua exclusão e a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a improcedência da ação e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, com a aplicação da sanção de advertência em razão da primariedade do réu. Por fim, caso entenda-se pela configuração do delito de tráfico, requereu a aplicação de apenamento mínimo, regime inicial aberto, redução do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É O RELATO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, insta analisar a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão. Ao contrário do alegado pelo proficiente Dr. Defensor, tal diligência foi levada a efeito com estrita observância aos ditames constitucionais e legais. Estabelece a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 5º, XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Como explicaram as testemunhas, Wellington Corredato da Silva e Fábio Portaluppi Marinho, em seus depoimentos em Juízo, após o recebimento da denúncia anônima, informando acerca da prática do delito de tráfico de entorpecentes por um indivíduo, no local dos fatos, foi realizada atividade de campana, tendo os policiais se posicionado bem próximos ao réu, momento em que puderam observar a venda de entorpecentes, sendo que ROGER entrava no imóvel, buscava o entorpecente e, então, o entregava aos clientes.

Assim, considerando tratar-se o tráfico de entorpecentes de crime classificado como permanente, ou seja, cuja consumação se protraí no tempo, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, de modo que, estando o autuado em situação de flagrância, como descrito pelas testemunhas supramencionadas, possível a violação do domicílio mesmo sem mandado judicial. Se não, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE.

NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente

quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 2. A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que “[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 3. Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Nesse sentido: RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento (HC 203210 ED, Rel.: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, publicado em 20/08/2021).

Assim, considerando que, no caso dos autos, os policiais civis em campanha observaram o réu buscar o entorpecente dentro do barraco e, em seguida, entregá-lo a duas pessoas, presentes fundadas razões para acreditar que em seu interior ocorria a prática do crime. Não se vê, portanto, qualquer irregularidade na realização de tal diligência, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A materialidade do delito restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 04, boletim de ocorrência às fls. 09/11, auto de apreensão exibição às fls. 12, laudo pericial de constatação às fls. 18/20, laudo químico-toxicológico de fls. 64/67, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Passo à análise da autoria.

Eis a prova oral colhida.

A testemunha WELLINGTON CORREDATO DA SILVA, policial civil, declarou em Juízo que na data dos fatos, receberam uma denúncia anônima na Delegacia dando conta que um indivíduo com camiseta de cores amarela e vermelha e shorts azul, estaria vendendo drogas na Rua dos Cravos. Foi para o local juntamente com o investigador Fabio e fizeram uma breve campanha, pois se posicionaram bem próximos do indivíduo em questão sem que ele percebesse a presença policial. Assim, puderam observar quando ele efetuou duas vendas para dois rapazes, sendo um de cor parda e o outro branco, ambos de estatura alta. Para não prejudicar o trabalho, permitiram que os dois fossem embora e pediram o apoio da outra viatura que estava de prontidão ali próximo, sendo que esta segunda viatura conseguiu abordar o acusado. Informou que foi apurado que, após contatos com os clientes, o indiciado se dirigia a um barraco, posteriormente identificado como sendo sua residência, onde pegava a droga e entregava aos clientes. Assim, com o apoio do canil, foi localizado em um buraco, embaixo da pia, 43 (quarenta e três) porções de crack e, em poder do acusado foi encontrada a importância de R\$ 29,00 (vinte e nove reais) em dinheiro. Declarou que não conhecia o acusado anteriormente.

A testemunha FÁBIO PORTALUPPI MARINHO, policial civil, declarou em Juízo que na data dos fatos, receberam informações de que na Rua dos Cravos havia um indivíduo vendendo drogas, sendo que estaria trajando camiseta nas cores amarela e vermelha, e shorts azul. Informou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas.

Dirigiram-se para o local em uma viatura descaracterizada e conseguiram se posicionar bem próximo ao indivíduo. Informou que ele estava de frente a um terreno, com um barraco abandonado e puderam visualizar quando ele efetuou a venda para duas pessoas, sendo que ele entrava nesse local, que só tem um cômodo e uma

cozinha, e saía com o entorpecente. Em seguida, pediram o apoio de outra equipe que estava nas proximidades, tendo ROGER sido abordado por eles. Após a abordagem, chamaram o canil e então encontraram, dentro do barraco, embaixo da pia, 43 (quarenta e três) porções de crack e em poder dele foi encontrada a importância de R\$ 29,00 (vinte e nove reais) em dinheiro.

Interrogado em Juízo, o réu ROGER APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA declarou que é usuário de drogas desde os 16 (dezesesseis) anos. Disse que estava devendo dinheiro para um dos rapazes da biqueira e, no dia dos fatos, já tinha usado drogas e foi até lá, com um veículo que havia emprestado, para tentar dar um aparelho celular em pagamento, porém não foi aceito. Estava na abstinência de usar, então voltou à biqueira, momento em que aceitou levar uma pequena quantidade de droga até o terminal rodoviário em troca de um pouco de droga e do perdão de sua dívida. No trajeto, foi abordado por uma viatura policial, sendo que revistaram o veículo e encontraram a droga e, questionado, se negou a informar de quem era a propriedade da droga, motivo pelo qual foi preso. Ao Ministério Público informou que fez tratamento no CAPS em razão de outro processo. O veículo em questão foi emprestado de um amigo chamado Saulo que tem um estacionamento na Av. Santo Antônio, um dia antes dos fatos, pois queria sair com sua namorada. Informou que não ofereceu dinheiro aos policiais que efetuaram sua prisão, até porque não tinha esse dinheiro. Declarou que o celular de sua propriedade que foi apreendido é o Samsung, branco e cinza.

Pois bem.

Ao cabo da instrução criminal, restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do delito narrado na denúncia. Nesse sentido é firme e segura toda a prova deduzida, notadamente em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim, em que pese a tese sustentada pelo nobre Defensor e a negativa da autoria pelo réu, a pretensão deduzida pelo Ministério Público comporta acolhimento.

Tanto na fase policial, como em Juízo, os policiais cuidaram de detalhar a abordagem policial e o desenrolar dos fatos, indicando de forma segura o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.

Segundo se apurou, os policiais civis dirigiram-se ao local dos fatos, onde realizaram atividade de campana, após receberem denúncia anônima dando conta de que ali ocorria crime de tráfico de drogas, sendo fornecida a descrição do indivíduo responsável. No local, puderam observar ROGER efetuar a venda de entorpecentes a duas pessoas, sendo que, após conversar com os clientes, se dirigia até o barraco, que usava como residências, buscava ali o entorpecente e, então, fazia a entrega. Em seguida, após sua abordagem, foi realizada busca no mencionado barraco, com a ajuda do canil da Polícia Militar, no qual foram localizadas 43 (quarenta e três) porções de cocaína. Ainda, em seu poder, foram apreendidos R\$ 29,00 (vinte e nove reais) em dinheiro.

O acusado, em seu interrogatório em Juízo, afirmou que aceitou levar uma pequena quantidade de droga até o terminal rodoviário em troca de um pouco de droga e do perdão de sua dívida. No trajeto, foi abordado por uma viatura policial, sendo que revistaram o veículo em que se encontrava e encontraram a droga. Declarou que foi preso pois se negou a informar quem era o proprietário do entorpecente.

Ressalte-se que o testemunho de policiais tem o mesmo valor probatório do depoimento de outras testemunhas, haja vista que submetido às mesmas regras referentes ao juramento e à pena de falso testemunho, além de também ser colhido sob o crivo do contraditório.

Assim, como qualquer outro meio de prova, o depoimento de policiais é, portanto, idôneo para fundamentar a condenação. De fato, não se pode presumir que as ações dos policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenham por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Para afastar o valor do testemunho de policiais, seria preciso a existência de indícios mínimos de injusta incriminação de inocentes, o que não ocorre no caso em questão, no qual a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta policial.

Assim, desacreditar a palavra dos policiais militares em contexto probatório desta envergadura mostra-se extremamente temerário.

Nesse sentido:

"O depoimento do policial é tão válido como outro qualquer, desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, indeclinável credibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas" (RT 574/401). E mais: "Os policiais não estão impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos em cuja fase inquisitorial tenham participado. A eventual inidoneidade tem que ser específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, pois o simples fato de ser a testemunha um policial não basta, por si só, para afastar a credibilidade de seu depoimento" (RT 594/332). Em idêntico sentido: RTs 394/282, 526/445, 554/420, 558/313, 568/315, 581/311; RJTJ 93/400 e 95/468, dentre tantos.

Repise-se que as justificativas apresentadas em autodefesa apresentam-se frágeis e inverossímeis, não encontrando respaldo nas demais provas, em especial à versão dos policiais, os quais declinaram que no dia dos fatos, visualizaram o acusado vender entorpecentes a duas pessoas, sendo que, após conversar com o cliente, buscava a droga dentro do barraco que utilizada como residência, sendo Roger abordado e encontrados em seu poder R\$ 29,00 (vinte e nove reais) em dinheiro. Ainda, após busca realizada com o apoio do canil da Polícia Militar, foram localizadas, no interior do seu barraco, 43 (quarenta e três) porções de cocaína.

Em conclusão, restou devidamente demonstrado que o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, o entorpecente apreendido. Desse modo, os depoimentos das testemunhas, a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido sugerem a prática da traficância.

Por oportuno, friso que o acusado não apresentou nenhuma reserva em relação aos policiais que depuseram em Juízo e fizeram a apreensão do entorpecente.

Cumprе registrar, ainda, que, para a caracterização do delito em tela não se exige que o agente tenha atingido a finalidade lucrativa, tampouco que ao agente tenha praticado a conduta de venda e/ou entrega do entorpecente a usuários. Isso porque o crime em tela é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento.

In casu, restou devidamente demonstrado que o réu tinha em depósito, para fins de tráfico, o entorpecente apreendido.

Portanto, considerando os relatos seguros dos policiais, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a procedência da ação, com condenação do réu é a medida que se impõe.

Pelos mesmos motivos acima elencados que comprovam a materialidade e a autoria delitiva, não merece acolhida a pretensão defensiva para que haja desclassificação do crime para aquele descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06, vez que para que isso ocorra, é preciso prova segura da exclusividade do porte para consumo próprio, o que, no caso, inexistе.

Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal.

O crime de tráfico é apenado com reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que foi apreendida pequena quantidade de drogas em poder do réu, sendo ele primário. Assim, atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal e por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem reprimendas maiores, fixo a pena base no piso, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Entretanto, ante a primariedade do réu e a não vinculação à organização criminosa, aplico a regra contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e reduzo a sua pena em dois terços (2/3), resultando a reprimenda em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo

legal, pena que converto em definitiva, por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável.

Presentes os requisitos do artigo 44, § 3º do Código Penal, substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, consistentes em: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, em local e condições indicados pela Central de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca; b) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA (art. 43, VI c.c. art. 48, ambos do CP), pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída.

No tocante ao regime da pena, considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis, bem como considerando a quantidade da droga apreendida, excepcionalmente, o regime inicial de cumprimento da pena será aberto, nos termos dos artigos 33, § 2º, "c" e § 3º, c/c 59, todos do Código Penal.

Face à substituição da pena privativa de liberdade, incabível se mostra a suspensão de sua execução (art. 77, III, do CP).

Anoto, por fim, que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada no presente julgamento (art. 315, §2º do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória postulada na denúncia para, dando-o como incurso na sanção do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, condenar o acusado ROGER APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA por duas penas restritivas de direito, consistentes em a) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, em local e condições indicados pela Central de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca; b) limitação de fim de semana (art. 43, VI c.c. art. 48, ambos do CP), pelo prazo da pena privativa de liberdade substituída, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Decreto a perda do numerário apreendido visto que não comprovada a origem lícita, revelando a prova que era proveniente do comércio ilegal de drogas.

Sem custas processuais, tendo em vista que o réu foi defendido por Patrono dativo, justificando a concessão de assistência judiciária.

Diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e ausentes os pressupostos da custódia cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade desta decisão.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guia de execução e o que mais que for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

P.I.C.

Marília, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA